论行政处罚对象的法定化*

□ 陈思融

内容提要 对于行政处罚对象,当前我国行政法规范层面上或是根本不提及,或是呈现出相当程度的随意性。行政处罚法定原则作为行政处罚领域的一项基本原则,其具体内容不能仅强调以行政机关面向为规范重点,局限于诸如行政处罚主体、内容、程序等具体制度层面的法定,而应当同时重点规范行政相对人面向,强调应受行政处罚行为的主体,即行政处罚对象的法定,以及应受处罚行为构成要件的法定。《行政处罚法》修订过程中,应明确行政处罚对象的一般性原则,以"行为人"为规范重点,辅以"状态责任人"制度,并结合比例原则对行政处罚对象的限制,制定专门条文规范行政处罚对象。

关键词 行政处罚对象 处罚法定原则 状态责任人 行为责任人 比例原则

作者陈思融,浙江财经大学法学院副教授,浙江大学光华法学院博士后。(杭州 310018)

DOI:10.14167/j.zjss.2020.11.006

引 言

"行政处罚是行政机关依法对行政相对人的违反行政法上义务行为所给予的一种法律制裁",[①]受制裁的违反行政法上义务的行政相对人,即为行政处罚对象。[②]我国行政法规范层面上对行政处罚对象的规定相当抽象,甚至根本未明文规定。作为行政处罚领域总则性质的《行政处罚法》抽象地将行政处罚对象称为"公民、法人或其他组织"(如第3条、第30条)或者"当事人"(如第23条、第24条),对于公民、法人或其他组织的范围,以及当事人是否就等同于违法行为人等均未予以明确。其他行政法规范中有关行政处罚的规定,常常以"违反本法(条例)规定的违法行为+实施行政处罚的主体+处罚种类"的形式予以规定,其并不明确规定行政处罚的对象,并且在具体设定行政法义务的条款中通常也未明确义务人。例如《道路运输条例》第63条规定:"违反本条例的规定,未取得道路运输经营许可,擅自从事道路运输经营的,由县级以上道路运输管理机构责令停止经营……"在该条文中只明确揭示行政处罚的事实根据,即违反行政管理秩序的行为"未取得道路运输经营许可,擅自从事道路运输经营的",实施行政处罚的主体"县级以上道路运输管理机构",以及处罚的种类"责令停止经营",而对于责令停止经营处罚的处罚对象并未予以明确。如果驾驶员A驾驶B所有的无道路运输经营许可证的汽车从事道路运输经营的,应以驾驶员A为行政处罚对象,还是应以汽车的所有权人B为行政处罚对象?此时即可能造成因行政机关处罚对象选择错误而引发行政纠纷和诉讼。

另外,我国《行政处罚法》并未明确规定行政

*本成果系浙江省地方立法与法治战略研究院(智库)研究项目"《行政处罚法》修改重大问题研究:理念及其制度创新"的研究成果。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

处罚必须以行为人主观上存在过错为条件，早期我国行政法理论界一般也主张客观归责原则，即“在行政责任构成中并不以主观状态为必要要件，而是强调违反行政法义务，破坏行政管理秩序的行为”，[③]由此，在行政处罚实务运作过程中，行政处罚对象的选择几乎是取决于行政机关，只要认定客观上有违反行政法律规定的事实状态，行政机关便可直接加以处罚，从而忽视违反行政法上义务者的审查。由此经常出现对行政处罚对象产生争议的实例，例如挂靠车辆的挂靠者利用被挂靠者所获得的资质，实施违反行政法律的行为，其行政处罚对象应是挂靠者还是被挂靠者；再如对于委托加工情形下，由于涉及产品生产的委托方和加工方两个生产者，当发生产品质量违法行为时，其行政处罚对象应是委托方还是加工方。可以说，我国当前对于行政处罚对象的立法，远远不能适应行政执法的现状。

但长期以来，面对上述立法与执法实践中存在的问题，我国行政法学界和实务界对行政处罚对象议题的探讨却相当零星。[④]学者们对行政处罚领域的研究，更多地集中在“应受行政处罚行为的构成要件”、[⑤]“行政处罚的程序”[⑥]等问题的研究。在法学理论上深入研究行政处罚对象问题，对于促进《行政处罚法》中有关行政处罚对象规定的修改以及行政执法领域行政处罚对象的认定，具有重要理论和实践意义。

一、行政处罚法定原则的内涵

行政处罚法定，是指法无明文规定不为违法，法无明文规定不受处罚。[⑦]其作为行政处罚的基本原则，在我国已经得到学理上的认可以及实在法的确认。笔者认为，学理以及实在法上的行政处罚法定原则，其内涵均应包括行政处罚对象的法定。

对于行政处罚法定原则的内涵，学理上有着不同的见解，主要包括四层内容说和六层内容说。主张四层内容说的学者认为处罚法定原则包含四层要求：处罚的主体及其职权法定、处罚的种类法定、处罚的依据法定、处罚的程序法定。[⑧]主张六层内容说的学者认为行政处罚法定原则除包含上述四层要求外，还包括应受处罚的行为法定以及处罚设定权法定。[⑨]比较上述两种观点，不难发现两者都更偏向强调“处罚行为”本身的法定，即行政机关实施行政处罚过程中要求的处罚主体、依据、程序以及种类的法定，而对于“应受处罚行为”的法定，即行政相对人的何种违法行为应受到处罚却有所忽视。虽然主张六层内容说的学者认识到“应受处罚行为”的法定同样属于行政处罚法定原则应有之内涵，但相较于对处罚行为法定的详细解读而言，对应受处罚行为法定的解读则显得较为单薄，仅强调“只有法律、法规 、规章明确规定，公民 、法人或者其他组织的某种行为是属于违反行政管理秩序的行为，应予以处罚，该行为才能被处罚。”[⑩]而对法应如何明确应受处罚行为则无进一步的阐述。

理论上，应以行政处罚法定原则的价值为基础确定该原则的具体内容。行政处罚法定原则的核心价值在于控制和规范行政权，[⑪]而对行政处罚权的控制和规范，“除了行政机关的视角，亦有相对人的视角”，“转换成行政相对人的角度，可以跳脱出规范主义、程序主义以及司法审查的传统控权结构”。[⑫]处罚法定原则可以以行政机关为面向，设定一系列限制行政处罚权运行的标准，同时也可以以行政相对人为面向，从违反行政义务的相对人以及相对人行为达到何种标准才能予以处罚的立场，为行政处罚权提供科学的启动标准和运行法则。以行政相对人角度控制和规范行政处罚权，即应当是围绕“违反行政法义务的相对人”以及“行政相对人行为达到何种标准才能予以处罚”构建控权模式。前者具体体现为应受行政处罚行为的主体，即行政处罚对象，后者具体体现为应受行政处罚行为的构成要件。[⑬]因此，行政处罚对象的法定应当是行政处罚法定原则的当然内涵。

在规范层面上，我国《行政处罚法》第3条第1款明确了行政处罚法定原则，仔细解读该条规定，可以发现我国制度层面上的行政处罚法定原则包含两个方面的内容：“违反行政管理秩序的行为，应当给予行政处罚的”体现出“应受处罚行为”法定，“依照本法由法律、法规或者规章规定，并由行政机关依照本法规定的程序实施”体现出“处罚行为”的法定。“前者面向相对人，后者面向行政机关。”[⑭]对于处罚行为的法定，《行政处罚法》将其具体化为处罚的主体、依据、程序应由法加以明确规定；而对于应受处罚行为的法定，《行政处罚法》仅仅概括性地规定了应当给予行政处罚这一标准。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

由此可以发现，我国制度层面的行政处罚法定原则同样以行政机关面向为规范重点,“对于行政机关这一面向的偏重很有可能导致面向相对人的‘应当给予行政处罚’这一面向被虚置”。[15]“应当给予行政处罚”，其逻辑应当是“存在行政法上义务——谁应当履行该行政法上义务——违反行政法上义务——进行行政处罚”,根据该逻辑作出行政处罚,首先在于有行政法义务的违反,而行政法义务的违反，又以有违反行政法义务的行政相对人为前提。也就是说,行政法义务内容的决定应该联结义务的主体,即行政处罚对象,如立法不明确行政处罚对象的范围,行政机关则会自行认定,从而产生处罚对象范围的扩大,或处罚对象的漏洞,违反行政的目的。

在“顾建祥以其是登记上的所有人而非实际上的所有人不服海宁市交通局行政处罚决定案”[16]中,驾驶员戴某驾驶顾某的夏利轿车拉客,因该车无道路运输经营许可证,该市交通局依照 1998 年 3 月 9 日发布的《道路运输行政处罚规定》第 8 条第 1 项[17]之规定，给予顾某罚款人民币 8500 元的行政处罚。二审法院认为:“被上诉人(交通局)认定戴某(驾驶员)从事违法载客经营活动,却处罚车主(顾某),违反了法无明文规定不处罚的原则,属处罚对象错误。”二审法院判决撤销交通局的行政处罚决定。该案中行政机关并未对违法行为人戴某作出处罚,而是对轿车所有权人作出了处罚,行政机关扩大了处罚对象的范围，其根本原因即在于 1998 年《道路运输行政处罚规定》第 8 条第 1 项仅明确有持道路运输经营许可证从事道路运输经营的义务,但并未明确应履行该义务的主体,罚款处罚的对象亦未明确。[18]在“吉林市公安局交通管理支队与朱启江行政检察案”[19]中,一审法院指出:“交通违法行为被处罚的对象主要是车辆驾驶人,而非机动车,其目的是惩戒和警示、避免违法驾驶行为的再次发生。车辆年检的对象是车辆本身,其目的是及时消除车辆的安全隐患、减少因车辆本身的状况导致的交通事故的发生。将交通违法行为的处理设定为核发车辆检验合格标志的前提条件,两者对象不一致。”该案虽并非因处罚对象错误而引发，但判决书中法官对处罚对象的分析，同样深刻反映出处罚对象适格对实现行政目的重要作用。因此,“应受处罚行为”法定作为我国制度层面上的处罚法定原则之内容，其具体内容应当包括处罚对象的法定。

综上所述，处罚对象法定应当是行政处罚法定原则的当然内涵。“在确定具体的处罚对象时，应当坚持法定原则”，[20]我国的行政处罚法定原则不应包括行政处罚对象的法定，即对处罚对象的范围或者选择标准予以明定，无论是规范于总则性质的《行政处罚法》或是其他个别行政法规范，皆应明确规范,避免根本未规定行政处罚对象,或概括地以“公民、法人、其他组织”及“当事人”的方式规范。

二、行政法规范层面的行政处罚对象

在我国行政法规范层面上，作为行政处罚领域总则性质的《行政处罚法》对行政处罚对象的规定缺乏明确性，而其他行政法规范中有关行政处罚的规定,或是根本不提及行政处罚的对象,或是呈现出行政处罚对象规定的相当程度的随意性。主要体现为以下几方面:

(一)将“物”作为行政处罚的对象

行政处罚对象，作为行政处罚法律关系的一方当事人,属于行政处罚法律关系的主体,其也可以称为应受行政处罚行为的主体,“物”在法律关系中通常作为客体存在，但我国行政法规范中却存在将“物”作为行政处罚对象的规定。例如《海洋环境保护法》第 78 条:“违反本法第三十九条第二款的规定，……责令非法运输该危险废物的船舶退出中华人民共和国管辖海域，并处五万元以上五十万元以下的罚款。”该条文中,规定作出罚款行政处罚的对象为“船舶”。“船舶”显然不属于公民或者法人的范畴，那其是否可以归于“其他组织”呢？由于法律要求船舶像人一样须有船名、国籍、船籍港,并且船舶在航行中形成了与船长、船员结合一体的严密组织机构，因此有学者认为船舶是具有着“一般物所不具备的人格性”,[21]在中国现有的法律框架下,可以“把船舶作为非法人组织设置”。[22]但根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第 52 条的规定,“其他组织”是指合法成立、有一定的组织机构和财产,但又不具备法人资格的组织。船舶虽然可以满足“合法成立”、“有一定的组织”这两项条件,但由于船长船员登船工作时不可能以货币或者其他

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

有形资产出资,船舶作为组织不具备财产基础,而不能成为“其他组织”。

在法律上,船舶应当是作为“物”而存在,我国现行行政法规范中将“船舶”这种法律上的“物”作为了行政处罚的对象。类似的规定还有《内河交通安全管理条例》第65条:“违反本条例的规定,……对船舶、浮动设施所有人或者经营人处1万元以上10万元以下的罚款;逾期不改正的,责令停航或者停止作业。”依该条文,海事管理机构作出的罚款,责令、停航行政处罚的对象是“船舶”、“浮动设施的所有人或经营人”。由此,在行政执法实践中,船舶作为行政处罚对象的情况大量存在。[23]

(二)为他人行为之代理人致本人违反行政法义务时的行政处罚对象规定存在随意性

在我国行政法规范中,对于为他人行为之代理人,致本人违反行政法上义务时处罚对象如何判定的问题,我国行政法规范中或者没有明确规定,或者规定并罚代理人和本人,或者规定仅处罚代理人。

例如《进出境动植物检疫法》第12条规定:“货主或者其代理人应当……,向进境口岸动植物检疫机关报检。”该法第39条规定:“违反本法规定,有下列行为之一的,由口岸动植物检疫机关处以罚款:(一)未报检或者未依法办理检疫审批手续的;……”根据上述法条规定,当代理人有未报检或者未依法办理检疫审批手续的违法行为,致使货主(本人)违反行政法上义务,究竟应对货主处以罚款,还是应对代理人处以罚款,抑或是对两者都处以罚款,法条并未明确罚款行政处罚的处罚对象。《海关行政处罚实施条例》第25条第2款规定:“……,进出口货物收发货人及其代理人未按照规定向海关如实申报有关知识产权状况,或者未提交合法使用有关知识产权的证明文件的,可以处5万元以下罚款。”由此,如实申报有关知识产权状态等行政法义务的义务人为“货物收发货人及其代理人”,当代理人有未如实申报知识产权状态行为时,同样会导致货物收发货人违反行政法上义务,根据文义解释,此时应当并罚“货物收发货人”和“代理人”。《税收征收管理法实施细则》第98条规定:“税务代理人违反税收法律、行政法规,造成纳税人未缴或者少缴税款的,除由纳税人缴纳或者补缴应纳税款、滞纳金外,对税务代理人处纳税人未缴或者少缴税款50%以上3倍以下的罚款。”由此,税务代理人的违法行为造成纳税人违反行政法上义务时,纳税人只需缴纳或补缴纳税款、滞纳金即可,由于缴纳或补缴税款、滞纳金并非行政处罚,即此时纳税人并非行政处罚的对象,而只对税务代理人作出罚款的行政处罚,税务代理人为罚款处罚的行政相对人。

(三)单位违反行政法义务时行政处罚对象的规定存在随意性

单位违反行政法义务时,我国行政法规范中往往在同一领域规定不同的行政处罚对象,呈现出较大的随意性。

以“单位”(包括法人和其他组织)违反治安管理秩序行为为例,我国先后有三部《治安管理处罚条例》和《治安管理处罚法》对其有所表述。1957年、1986年《治安管理处罚条例》规定机关、团体、学校、企业、事业单位违反治安管理的,处罚行政负责人、直接责任人员或者主管人员。2005年以及2012年的《治安管理处罚法》第18条则规定:“单位违反治安管理的,对其直接负责的主管人员和直接责任人员依照本法的规定处罚。其他法律、行政法规对同一行为规定给予单位处罚的,依照其规定处罚。”2017年1月16日公安部发布的《公安部关于〈中华人民共和国治安管理处罚法(修订公开征求意见稿)〉》第17条规定:“单位违反治安管理的,对单位及其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照本法的规定处罚。本法没有规定,其他法律、行政法规对同一行为规定给予单位处罚的,依照其规定处罚。法律、行政法规没有规定单位处罚的,对组织、策划、实施该违反治安管理行为的人依照本法和其他有关治安管理的法律、法规的规定处罚。”由上述规范内容可以看出,我国治安管理领域有关单位违反行政法义务时的行政处罚对象经历了一个变迁的过程:仅以单位内部人员作为行政处罚对象——以单独处罚单位内部人员为原则,单独处罚单位为例外——以单位、单位内部人员并罚为原则,以单独处罚单位为例外,以单独处罚单位内部人员为例外中的例外。这种变迁是否会因缺乏正当性以及理论依据而存在相当程度的随意性,值得我们思考。

在环境保护领域,有着总则性质的《环境保护

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

法》中,有六条内容涉及行政处罚,其中有五条规定行政处罚的对象为“企业事业单位和其他生产经营者”,即如果单位存在违反行政法义务的行为,则单独处罚单位;而仅有一条规定行政处罚的对象为“企业事业单位和其他生产经营者”以及“直接负责的主管人员和其他直接责任人员”,即如果单位存在该条规定的违反行政法义务的行为,则并罚单位以及单位内部人员。由此可以推知,《环境保护法》在设定行政处罚对象时,以单独处罚单位为原则,以并罚单位以及单位内部人员为例外。而同样属于环境保护领域的《海洋坏境保护法》第 90 条规定:“对违反本法规定,造成海洋环境污染事故的单位,除依法承担赔偿责任外,由依照本法规定行使海洋环境监督管理权的部门依照本条第二款的规定处以罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处上一年度从本单位取得收入百分之五十以下的罚款;直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,依法给予处分。”由此可以推知,《海洋环境保护法》在设定行政处罚对象时,以并罚单位及其内部人员为原则。同为环境保护领域的《环境保护法》、《海洋环境保护法》,对于单位违反行政法义务的行政处罚对象问题,前者以单独处罚单位为原则,以并罚单位以及单位内部人员为例外;后者以并罚单位及其内部人员为原则。这种在同一领域有关行政处罚对象规定的较大差异性,同样也反映出我国行政法规对行政处罚对象规定的相当程度的随意性。

三、行政处罚对象的法定化

对于行政处罚的对象,如果法律有明文规定在一定条件下处罚特定的对象,则可依其规定处罚,但我国行政法规范上,往往并未明确规定行政处罚的对象,而由主管机关自行裁量决定处罚对象,对于处罚对象选择的裁量标准亦未明确,造成行政处罚对象确定争议,因此应当在我国行政法规范中明确规定行政处罚对象,实现行政处罚对象的法定化。我国行政处罚对象的法定化应当考虑如下因素:

(一)状态责任人可以作为行政处罚对象

行政处罚对象为违反行政法上义务之人,因此其前提必须是行政法上课予其一定法定义务,而行政法规范中课予义务基本上是以个别法律明文规定。由于行政法的目的并不仅是在藉由规范人的行为而形成并维护一套行政法秩序,尚且包括维护社会共同生活所需求的安全性,而对于安全性造成威胁挑战的危害方式,不只是人的行为,还可能来自物(包括动物)的性质或状态,所以在德国以及我国台湾地区行政法领域,立法者据以设定行政法上义务的联结点,除了“人的行为”外,还有“物的状态”,前者一般称为“行为责任”,后者称为“状态责任”。[24]“行为责任”系指因作为或不作为而肇致公共秩序或公共安全之危害的责任;“状态责任”系指人民以法规之规定,对某种状态之维持具有义务,故对于物的状态,具有事实管领力者,得以负责之观点,课予排除危险、回复安全之义务。[25]并由此将上述违反行政法上义务者分别称为“行为责任人”以及“状态责任人”,行政处罚的对象既可能是行为责任人,也可能是状态责任人。

我国行政法体系中对行政法上义务的课予,主要是以“人的行为”为联结点,例如《行政处罚法》第 3 条第 1 款规定“公民、法人或者其他组织违反行政管理秩序的行为,应当给予行政处罚的……”,该条内容的规范表述中设定维护行政管理秩序的义务即是以人的行为为联结点,其将“违反行政管理秩序的行为”等同于“违反行政法上义务”,由此将“行为人”等同于“违反行政法上义务者”。再如《道路运输条例》第 63 条规定的“未取得道路运输经营许可,擅自从事道路运输经营的……”、《进出境动植物检疫法》第 39 条规定的“未报检或者未依法办理检疫审批手续的……”,其设定行政法上义务均是以“人的行为”为联结点。有学者也因此得出结论认为“我国行政法体系建立在‘行为’之上,不仅对行政权的控制着眼于行政行为,对行政相对人也紧紧(或为仅仅)围绕违法行为四字。”[26]

事实上,我国行政法规范中也存在着以“物的状态”为联结点设定行政法上义务的规范表述,例如《道路交通安全法》第 114 条规定:“公安机关交通管理部门根据交通技术监控记录资料,可以对违法的机动车所有人或者管理人依法予以处罚。对能够确定驾驶人的,可以依照本法的规定依法予以处罚。”当机动车所有人或者管理人并非驾驶人(行为人)时,“机动车所有人或者管理人”之所

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

以可以成为行政处罚的对象，其根本在于机动车所有人或者管理人对违法的机动车具有事实管领力，而非其实施了某种违反道路交通安全义务的行为，此处对机动车所有人或者管理人设定行政法上义务的联结点即为“物的状态”，其作为行政处罚对象时即为“状态责任人”。

由此，以“物的状态”为联结点，对物的状态具有事实管领力的“状态责任人”可以成为行政处罚对象，“法律主体可以通过其物权（如财产权）得以明确”，[27]但“物”本身并非属于“人”的范围，其根本不具有行政法律关系的主体地位，更无法作为行政处罚的对象。

（二）作为行政处罚对象的“行为人”内涵

行为责任人之所以成为行政处罚对象，是因为行为人的行为违反行政法上义务，因此何谓行政处罚中的“行为人”则直接关系行政处罚对象的认定问题。以行为人作为处罚对象时，原则上系以“行为人”本身为受处罚之主体，即实际从事违反行政法上义务的行为者，但当实际从事违反行政法上义务的行为者是为他人所为时，最典型的如代理人为本人从事一定的行为，以及单位内部人员为单位从事职务的行为，此时应当认定代理人或是单位内部人员为行为人，还是应当认定该他人为行为人，其判断标准为何？笔者以为，此时行为人之判断不能仅以形式上从事该行为者为准，而应探求实质上该行为效果或利益归属者为准。

“如同私法那样，在行政法领域中也存在代理个人或者组织行使权利或者权力、主张利益、履行义务的各种客观需要。”[28]目前我国公法领域尚未对代理制度有所着墨，故有关代理问题似仍依私法建构的代理制度为据。根据民法代理法律行为的相关制度，“代理法律行为生效，首先要求代理法律行为应当满足一般法律行为的生效条件；其次代理法律行为作为一种特殊法律行为，应当满足该特殊法律行为生效的特殊条件，即有代理授权。”[29]代理法律行为的生效，其法律效果在于该法律行为的效力归属于本人。当代理人为本人而实际从事了违反行政法上义务的行为时，如果代理人的违法行为是被代理人授权实施的，则代理法律行为因不满足一般法律行为的生效条件（内容合法）而不生效，该代理法律行为的效力不归属于被代理人，此时只有代理人为违反行政法上义务的“行为人”，被代理人不能成为违反行政法上义务的“行为人”，但此时由于被代理人授权代理人实施违法行为，这一授权行为本身即构成了违反行政法上义务的独立行为，被代理人的授权行为构成了违反行政法上义务的“行为人”；如果代理人的违法行为并未获得被代理人的授权，则代理法律行为因不满足代理作为一种特殊法律行为的生效要件（有代理授权）而不生效，该代理法律行为的效力仍不能归属于被代理人，此时只有代理人为违反行政法上义务的“行为人”，被代理人不能成为违反行政法上义务的“行为人”。

对于单位而言，其不同于自然人，其自身不能行为，而须由自然人代为行为，即对于单位违反行政法上之义务，在形式上违反行政法义务的行为一定是由单位内部人员所为，但此时判定作为行政处罚对象的“行为人”不应仅就形式上从事行为者为准，而应探求实质上该行为效果或利益归属者为准。在民法上，根据《民法总则》第61条、第105条以及第170条的规定，法人、非法人组织与代表人是一个人格，代表人以组织名义实施的行为，法律后果由组织承受，[30]“执行法人或者非法人组织工作任务的人员，就其职权范围内的事项，以法人或者非法人组织的名义实施民事法律行为，对法人或非法人组织发生效力。”由此，单位内部人员为单位从事的“职务行为”[31]，该行为的效力应当归属于单位，单位内部人员的某一违反行政法上义务的行为如果被认定为职务行为，其后果应由单位承担，此时单位为违反行政法上义务的“行为人”；单位内部人员的某一违反行政法上义务的行为如果认定不是职务行为，其后果由单位内部人员自行承担，此时单位内部人员为违反行政法上义务的“行为人”。

（三）比例原则对行政处罚对象规定的限制

比例原则在行政处罚对象领域主要体现为三方面内容：行政处罚对象须足以达成防止危害、维持秩序的目的，如违章建筑的拆除，应以屋主为相对人，若以承租人为相对人，由于其对该屋并无处分权能，故此种制裁无法达到目的，并不适当（适合性原则）；且无其他侵害较小之手段，如单位违反行政法义务时，如果单独处罚单位已经可以实现行政目的，则无必要再并罚单位

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

内部人员(必要性原则);行政处罚所欲实现的公共利益,不能与处罚对象所受处罚的损害显失均衡(狭义比例原则)。

单位违反行政法义务时是否采取并罚制度,必须考虑其是否违反比例原则。在单位违反某一行政法义务时,实际上只有一个行政违法行为,此时如并罚单位及单位内部人员,即有两个行政处罚对象,分别是单位、单位内部成员,由于处罚对象并不相同,其在制度形式上并未违反一事不再罚原则。[32]但针对同一行政违法行为,如违反者为自然人,仅以自然人为处罚对象处罚一次,而若违反者为单位时,则可能行为人为该行为须受处罚两次,甚或三次,行政目的对同一事件,竟会因违反者为自然人或单位而有不同处罚结果,其有违比例原则中的适合性原则。并且从整体观察而言,对于一个违反行政法上义务事件,对单位和单位内部人员分别处罚,其过度加重人民的财产上负担,有违比例原则中的必要性原则以及狭义比例原则。当然,根据不同情形,如果仅处罚单位仍无法实现行政目的,此时行政法规范上确可加重单位内部人员责任,除对单位予以处罚外,同时并罚单位内部人员,但必须于行政法上明文规定单位内部责任人违反行政法上义务的构成要件,使其成为一个独立的行政法义务规定,方符合行政处罚法定原则,同时也不违反比例原则的要求。

单位违反行政法义务时,以单位内部成员为处罚对象的转嫁罚制度[33]同样有违比例原则。所谓转嫁罚,"系由刑法概念而来,即法人无法为所有刑罚类型之对象,只能担负罚金(没收)之刑责,故可有法人之负责人即行为人来课予刑责。转嫁罚的立意便将法人责任转嫁到负责人及行为人之责任上,所以转嫁罚的重点在处罚自然人,而对于法人以制裁力小效果不彰为由,而忽视对法人的处罚。"[34]但在行政处罚相关法律规范规定的行政处罚种类中,处罚单位的类型往往较自然人多样化,对于单位违反行政法义务时,原则上以单位为处罚对象即可实现行政法目的,如果此时仍将处罚对象由单位转嫁至单位内部人员,则有违比例原则中的适合性原则。另外,由于单位具有自己的意志能力和行为能力,不能将单位的行为归结为个人行为,[35]因此在行政法上,通常情况下不能再以对单位处罚类型的缺失为由,将处罚对象由单位转嫁至单位内部人员,应仅能处罚单位为原则。

四、代结语

行政处罚对象的适格与否关系到行政处罚行为的合法性,以及行政处罚的目的能否实现,行政处罚对象的法定化能够避免行政机关任意裁量选择行政处罚对象。《行政处罚法》作为行政处罚领域的总则性规定,应将行政处罚对象的一般性原则规定明确,在对《行政处罚法》进行修改时,可以考虑制定专门条文规范行政处罚对象,先揭示行政处罚对象以"行为人"为主的宗旨,即除法律、法规另有规定处罚"状态责任人"外,以处罚"行为人"为主,同时明确行为人的认定应以实质上该行为效果或利益归属者为准;根据比例原则,如若需要加重单位内部人员的责任,则必须有法律、法规明文规定单位内部责任人违反行政法上义务的构成要件。因此,立法者可以考虑创设如下文本:"违反行政法上义务应受处罚者,除法律、法规另有规定外,以行为人为限。代理人行为致被代理人违反行政法上义务,其行为效果或利益不归属于被代理人,该代理人为行为人;对被代理人作出行政处罚,以法律、法规有特别规定者为限。单位内部人员因执行其职务的行为,致单位违反行政法上义务,其行为效果或利益归属于单位,该单位为行为人;对该单位内部人员作出行政处罚,以法律、法规有特别规定者为限。"

注释:

①章剑生:《现代行政法基本理论》(第二版),法律出版社2014年版,第355页。

②有学者认为,行政处罚对象是违反行政管理秩序的行为。参见刘莘:《行政处罚问题研究》,《行政法学研究》1994年第3期;尹培培:《双重面向之处罚法定原则的困境及其出路——基于法的明确性原则》,《法律科学》2017年第5期。笔者认为,行政处罚的对象是违反行政法上义务的行政相对人,而非违反行政管理秩序的行为。违反行政管理秩序的行为是依附于违反行政法上义务的行政相对人而存在的,其是行政处罚的事实根据和理由。

③皮纯协等:《行政处罚法原理与运作》,科学普及出版社1996年版,第56页。

④已有的文献主要集中关注环境、食品卫生、检验检疫等某一具体行政领域的行政处罚对象问题。参见任静:《关于环境法中行政处罚对象的探讨》,《中国环境管理》1989年第1期;林何燕:《浅谈进境木质包装检疫中行政处

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

罚对象的确定》,《植物检疫》2007年第6期;程显波:《保荐人高管是否为证监会行政处罚对象问题研究》,《法律适用》2014年第10期;等等。

⑤从上个世纪90年代开始,学术界以行政罚款为例围绕"主观过错"是否构成行政处罚的构成要件进行了激烈讨论。参见袁曙宏:《略论行政罚款的构成要件》,《中南政法学院学报》1987年第2期;姜明安:《行政违法行为与行政处罚》,《中国法学》1992年第2期;熊樟林:《应受行政处罚行为构成要件的个数——判断一事不二罚的根本途径》,《政治与法律》2012年第8期;等等。

⑥叶必丰:《论行政处罚程序》,《法学评论》1990年第4期;朱芒:《行政处罚听证制度的功能——以上海听证制度的实施现状为例》,《法学研究》2003年第5期;石肖雪:《行政处罚听证程序适用范围的发展——以法规范与案例的互动为中心》,《华东政法大学学报》2013年第6期;等等。

⑦叶必丰:《行政法学》(修订版),武汉大学出版社2003年版,第253页。

⑧应松年主编:《行政法与行政诉讼法学》,高等教育出版社2017年版,第186页;胡建森主编:《行政法学》,复旦大学出版社2003年版,第196页;等等。

⑨姜明安主编:《行政法与行政诉讼法》,北京大学出版社、高等教育出版社2007年版,第314页;关保英主编:《行政处罚法新论》,中国政法大学出版社2007年版,第24~26页;等等。

⑩一今:《论行政处罚的法定原则》,《法律适用》1996年第8期。

⑪吴锦标:《行政处罚法定原则及其法律价值》,《法律适用》2005年第9期。

⑫熊樟林:《论〈行政处罚法〉修改的基本立场》,《当代法学》2019年第1期。

⑬由于本文主题限制,对于应受处罚行为构成要件的法定,本文不作深入探讨。

⑭⑮尹培培:《双重面向之处罚法定原则的困境及其出路——基于法的明确性原则》,《法律科学》2017年第5期。

⑯具体案情见最高人民法院中国应用法学研究所编:《人民法院案例选》,人民法院出版社2000年第3辑,第352页。

⑰《道路运输行政处罚规定》第8条第1项:"对违反经营许可管理的行为,按下列规定予以处罚:(一)无道路运输经营许可证擅自从事道路运输经营活动的,处以5000元以上10000元以下的罚款。"

⑱因法未明确处罚对象导致的行政处罚对象选择错误而引发的案例还可参见:"重庆市安泰运输有限公司诉赣州市烟草专卖局行政处罚决定案",江西省赣州市中级人民法院(2012)赣中行终字第25号行政判决书;"楼月秋不服东阳市技术监督局行政处罚决定案",浙江省东阳市人民法院(2000)东行初字第37号行政判决书;等等。

⑲具体案情见吉林省吉林市中级人民法院(2019)吉02行终第43号行政判决书。

⑳江必新主编:《行政处罚及其司法审查实用大全》,中国人民公安大学出版社1996年版,第394页。

㉑田田:《海商法上船舶的法律属性研究》,《政法论坛》1999年第5期。

㉒倪建秋:《对船舶拟非法人组织行政处罚的合理性探析》,《中国海事》2006年第6期。

㉓以长江下游某分支海事局为例,2013年对以船舶为对象的行政处罚案件一共办理423件,占行政处罚案件总数的68.67%;2014年为280件,占案件总数的69%。参见曹缪辉:《论海事行政处罚中的船舶相对人》,《中国海商法研究》2015年第3期。

㉔李建良:《行政法上义务继受问题初探——兼评高雄高等行政法院九十二年度诉字第八〇六号判决暨最高行政法院九十四年度判字第六二二号判决》,载汤德宗、刘淑范主编:《2005行政管制与行政争讼》,2006年中央研究院筹备处专书,第81页。

㉕尤重道:《行政罚责任概念与责任类型暨责任竞合问题之探讨》,《全国律师》2012年第7期。

㉖夏雨:《以物为中心——违法建筑行政处罚相对人认定新路径》,《江淮论坛》2010年第5期。

㉗㉘[德]汉斯·J.沃尔夫等:《行政法》(第一卷),高家伟译,商务印书馆2002年版,第474、437页。

㉙叶于博:《代理规则:法律行为成立效力归属的判断规则》,《河北法学》2014年第4期。

㉚沈德咏:《中华人民共和国民法总则条文理解与适用》(上),人民法院出版社2017年版,第475页。

㉛此处的"职务行为",并非指行政法上国家机关工作人员的职务行为,而是借鉴民商法维度的职务行为的法律概念。

㉜㉟杨解君:《对法人行政违法的"两罚"处罚》,《中南政法学院学报》1994年第1期。

㉝所谓"转嫁罚",系指实际行为人不受处罚,而将责任转嫁给他人受罚。参见蔡震荣、郑善印:《行政处罚法逐条释义》,新学林出版股份有限公司2008年版,第263页。

㉞陈新民:《行政法学总论》,三民书局出版社2005年版,第419页。

责任编辑 陈亚飞

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Coopetitionism: Reconstructing the Paradigm and Security under Anarchy (23)

Chu Zhaogen

(*Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018*)

Abstract: Anarchy is the starting point of the research and logic of the three major IR theories. Using the deductive approach, based on the two contradictory assumptions of anarchy and complex interdependence put forward by the two classical IR theories, neo-realism and neo-liberalism respectively, this paper deduces a new and fourth interpretation of anarchy in today's world, that is anarchy has evolved into a new state of coopetition from the three mainstream IR theories, in which competition replaces conflict, cooperation replaces confrontation, and competition and cooperation interact and coexist. On the coopetition state, Coopetitionism is put forward on the integration and exploitation of the essence of different theories, thus realize the advancement of the three mainstream IR theories.

Key words: coopetitionism; anarchy; complex interdependence; competition; cooperation

Policy Failure and Avoidance Mechanism——Responsibility Issues in the Process of Scientific Decision-making and Democratization (34)

Liu Ran

(*School of Government, Nanjing University, Nanjing 210023*)

Abstract: Public policy has embarked on a scientific and democratic road, expert consultation and public participation are considered to be effective ways to control bureaucratic power and make bureaucrats do their duty. However, in the decision-making mechanism composed of "government-expert-public representative", policy responsibility is also diluted and differentiated due to plural decision-making subjects. Although existing decision-making system emphasizes the role of experts and the public, it does not give them enough power to act effectively. It may not lead to the "responsibility sharing" situation, but the bureaucrats use the differences in the scope of responsibility of the parties involved, the subject of accountability and the way of responsibility, forming a kind of blame-avoidance mechanism. "Scapegoat strategy", "compromise rather than merit", "constrain policy agenda" and "customize external opinions" are strategic actions driven by government officials under the motive of avoidance. The scientific and democratization of policies is born to prevent bureaucracy, but in operation it may be assimilated and become the umbrella of bureaucratic in policy failure.

Key words: decision-making responsibility; scientific decision-making; expert responsibility; blame-avoidance mechanism

The Cooperative Development Mechanism of Intellectual Property and Standards (42)

Dong Yupeng[1], Jin Pengnian[2]

(1. *NingboTech University, Ningbo 315100*; 2. *School of Law, Zhejiang University, Hangzhou 310058*)

Abstract: The sustainable economic and social development of China relies on upgrading technological innovation, by which the industry chain continues to move from a low level to higher one. With the deepening development of the global economic pattern, intellectual property and standard, as the bridge and carrier of the technological innovation, are increasingly becoming the strategic resource of the core elements of global competitiveness. The coordination of intellectual property and standard would become not only an important content of innovation governance, but also an urgent need for further promotion of the national strategy. The full integration of intellectual property and standard would maximize the innovation performance and industrial benefits. It is of great practical significance to study the conflict and overlapping relationship between intellectual property and standard, to build a policy regulation mechanism, to strengthen the layout of key industrial standards and patents and form a new innovation organization mechanism.

Key words: intellectual property; standards; collaborative innovation; driving mechanism

Study on the Legalization of the Object of Administrative Penalty (48)

Chen Sirong

(*School of Law, Zhejiang University, Hangzhou 310018*)

Abstract: The current administrative law in our country does not mention the object of administrative penalty at all, or shows a considerable degree of arbitrariness. As a basic principle in the field of administrative penalty, the legal principle of Statutory Punishment should not only focus on the orientation of administrative organs, such as the statutory of subject, content and procedure of administrative penalty on the specific institutional level, but also focus on the orientation of the administrative counterparts, emphasizing the subject of acts subject to administrative penalty, that is the statutory object of administrative penalty, and

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

the statute of the constitutive elements of punishable acts. The general principle of the object of administrative penalty should be clearly defined in the Administrative Penalties Law, with the focus on the "actor" as the norm, supplemented by the "state responsible person" system, and combined with the principle of proportionality to restrict the object of administrative penalty, special provisions should be formulated to regulate the object of administrative penalty.

Key words: object of administrative penalty; principle of statutory punishment; state responsible person; behavior responsible person; principle of proportionality

The Third Breakthrough: Communication Semiotics in the Context of New Technology (56)

Li Siqu, Zang Jinying

(*College of Media and International Culture, Zhejiang University, Hangzhou 310028*)

Abstract: So far, semiotics has made two major breakthroughs. The first happened in the early 20th century. In the context of the Industrial Revolution, linguists like Saussure and Pierce crossed the disciplinary boundaries of linguistics and logic and began to probe into the issue of meaning. The second occurred in the middle and late 20th century. With the development of modern communication technologies and mass media, scholars like Roland Barthes and Umberto Eco transcended pure logical deduction, and turned their foci on the practical applications of popular culture. Today, semiotics is undergoing the third breakthrough, which is a re-start towards the critical problems of belief reconstruction and value dissemination in the age of 5G, AI and genetic engineering. This article sorts out the development of communication semiotics since 1950s, and discusses the development trend of communication semiotics from perspectives of basic theoretical construction, social innovation activation and cultural production empowerment. The trend is as follows: paying attention to the issue of belief reconstruction and value dissemination in the era of new technology clusters, absorbing new achievements in cognitive science and digital technology, and, on the basis of spiritual semiotics and the theory of value dissemination expanding the research area of communication semiotics to promote dialogue among civilizations in the world and construct the community of shared future for mankind.

Key words: communication semiotics; value dissemination; spiritual semiotics; artificial intelligence

Consumption Justice: Why Is It Necessary? (64)

Yu HaiShan

(*Zhejiang International Studies University, Hangzhou 310023*)

Abstract: The wide existence of consumption injustice calls for the research of consumption justice from the theoretical perspective. The foundation of the theory should be based on its definition, connotation, and extension. Consumption justice is defined as that if one's consumption does not pose any harm to nature, others or itself. There are three sub-goals, including natural justice, social justice, and human justice. These sub-goals are categorized in such because consumption can have a severe impact on nature, society, and humans. That is also why it's necessary to research consumption justice.

Key words: consumption justice; natural justice; social justice; human justice

Analysis on the Evolution of China's Social Mobility Mechanism from the Perspective of Institutional Transformation (70)

Guo Dongjie

(*School of Management, Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310023*)

Abstract: Over the past 40 years, the reform and opening up policy, which is mainly induced institutional change and supplemented by mandatory institutional transformation, has been an important driving force for China's progress. With the rapid economic growth, social mobility has intensified and the hierarchical system has been reshaped. In the gradual institutional transformation, the forces between the government and the market, or between power and economy, are adjusted by social relations. The mechanism of social mobility changes with time. The gradual institutional transformation is prone to path dependence, forming a cumulative problem – super scale floating population or migrant workers. The single system reform of fragmentation has been unable to do anything about it. We need to design a systematic reform plan at the top level to eradicate structural obstacles and tend to fairness and justice; we should give full play to the advantages of the system and reduce the pre imposed obstacles. Through correcting market failure, narrowing income gap, targeting poverty alleviation, breaking capital monopoly and promoting equalization of public services, creating equal opportunities for all walks of life, a long-term social stability is achieved.

Key words: institutional transformation; social mobility; social stratification; social relations; government; market

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net